

1500402-75.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... inadequada, já que o réu está respondendo processo por tráfico de drogas e furto, o que indica que a substituição do artigo 44 do Código Penal não é suficiente para a repressão e prevenção dos delitos. Afora isso, admitir uma pessoa usuária contumaz de droga prestar serviços em escolas e outras entidades públicas, colocaria em risco as pessoas que delas se utilizam, inclusive ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500402-75.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500402-75.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2064690/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 23469703 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2064690 - 01º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO GOMES FERNANDES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500402-75.2022.8.26.0603 (Controle nº 567/2022).

Vistos.

BRUNO APARECIDO GOMES FERNANDES, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi preso em flagrante, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, §§1º e 4º,

incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 08 de março de 2022, por volta das 22h00min, na Rua Jairo Ferreira de Camargo, nº 290, Aeropark, cidade e comarca de Birigui, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com terceiro ainda não identificado, subtraiu para si 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A31; 1 (um) celular da marca Samsung, modelo J7; 1 (um) televisor smart TV, marca Semp Toshiba, 43 polegadas; 1 (um) videogame Playstation 2, da marca Sony; 8 (oito) cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard; 1 (uma) mochila escolar de cor cinza; diversas joias e 1 (uma) aliança em ouro, pertencentes a Luciano da Silva Oliveira e avaliados conforme fl. 76.

A denúncia foi recebida 22 de março de 2022 (fls. 87/88), e o réu foi regularmente citado (fl. 102), apresentando defesa escrita às fls. 112/118.

Durante a instrução criminal, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do acusado (fls. 161/162).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 165/170).

Por outro lado, a defesa o reconheceu a atenuante da confissão espontânea e da menoridade penal relativa; a aplicação da pena no mínimo legal; fixação do regime aberto, com a expedição de alvará de soltura (fls. 174/176).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que tem por finalidade apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a caracterizar o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, na forma consumada (artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após uma atenta análise das provas reunidas nos autos, não se pode deixar de reconhecer que a materialidade e as autorias dos fatos descritos na denúncia ficaram totalmente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01; o recibo de entrega de preso de fls. 02/03; a nota de culpa de fl. 09; o boletim de ocorrência de fls. 15/19; o auto de apreensão e exibição de fl. 20; o auto de avaliação de fl. 76; o relatório policial de fls. 78/79; o laudo pericial de fls. 105/108; as declarações da vítima; os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pelo acusado em ambas as fases da persecução penal.

Na delegacia e em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. Disse que, durante a noite, juntamente com outro indivíduo que não quis identificar, furtaram uma residência, mediante arrombamento, subtraindo vários objetos e ficou com apenas dois celulares. Posteriormente, foi fumar maconha com seu amigo Rafael, quando foram abordados por policiais militares, perguntando do celular. De imediato, confessou a prática do crime e disse que o adolescente Rafael não participou. Em juízo, disse que estava passando necessidades e precisava de dinheiro para pagar aluguel e comprar alimentos (fls. 08 e 161/162).

Como se vê, apesar de ter confessado a subtração em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, o réu alegou estado de necessidade.

Quanto à subtração em si, a confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

Todavia, a justificativa apresentada para o ato restou isolada e não passou de mero expediente utilizado na tentativa de amenizar sua responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, a vítima Luciano da Silva Oliveira, ouvido na delegacia, relatou que, por volta das 22h23m, chegou em sua residência e percebeu que o portão basculante da garagem de sua residência estava entreaberto e a porta de entrada do imóvel estava com a fechadura arrombada. No interior do imóvel, percebeu que tinham sido subtraídos vários objetos. Acionou a polícia militar e passou rastrear seu aparelho

celular subtraído e passou a localização aos policiais. No local informado, os policiais avistaram dois indivíduos e os indagaram a respeito do celular, neste momento, um dos indivíduos, chamado Bruno Aparecido Gomes Fernandes, confessou que havia furtado a residência e estava com os celulares subtraídos (fl. 06). Nos delitos de furto, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas é de excepcional importância, sobretudo quando harmoniosa e coincidente com o conjunto probatório, como é o caso.

As testemunhas Mateus Henrique de Souza Lopes e Reinaldo Cosme da Silva, policiais militares, ouvidos na delegacia e em juízo, disseram que atenderam a ocorrência. No local, A vítima estava monitorando o GPS de um dos seus celulares que havia sido subtraído naquela noite e informou a localização do aparelho celular. Deslocaram até o local e, avistaram dois indivíduos sentados na calçada. Indagados, Bruno Aparecido afirmou que, momentos antes, havia feito um furto em uma residência, com uma terceira pessoa, que não quis identificar, mas não era o adolescente Rafael, que estava sentado com ele. Com o acusado estavam apenas dois aparelhos celulares pertencentes à vítima. Os demais bens não foram localizados (fls. 02/03, 04/05 e 161/162).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Por fim, a testemunha Rafael Dias Pedrosa, ouvido na delegacia, disse que, naquela noite, estava sentado na calçada com seu amigo Bruno Aparecido Gomes Fernandes, que o chamou para "fumar um baseado". Quando surgiu uma viatura da polícia militar, indagando-os a respeito de um aparelho celular que havia sido furtado, e que o GPS deste aparelho estaria apontando aquele local. De imediato, Bruno confessou aos policiais que havia furtado uma residência com um outro indivíduo que não quis identificar, e que um dos aparelhos de telefone celular que ele havia furtado estava com ele naquele momento. Esclareceu que não participou do furto, não tinha conhecimento de que ele havia praticado tal crime, e que o acusado estava com os aparelhos celulares subtraídos (fl. 07).

No tocante aos depoimentos da testemunha Rafael e da vítima Luciano, ouvidos somente na fase policial, constato que não há, no caso, ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal, em sua nova redação dada pela Lei nº. 11.690/08, porque a convicção, aqui, não está formada apenas e exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, mas sim nesses elementos, que encontram respaldo nas demais provas produzidas em juízo, tendo sido obedecido o chamado "princípio da judicialização das provas".

Neste sentido, confira a lição de Andrey Borges de Mendonça, em sua obra "Nova Reforma do Código de Processo Penal", Editora Método, 2008, páginas 155/157: "... o legislador não vedou que o magistrado considere os elementos informativos produzidos durante o inquérito policial para a condenação. A restrição constante é que o magistrado considere exclusivamente os referidos elementos. A contrario sensu, é possível que sejam reputados na sentença condenatória elementos produzidos durante o inquérito policial, desde que apenas como reforço às provas produzidas em juízo (aqui sim em observância do contraditório). Dito de outra forma: o juiz pode levar em conta as provas produzidas no inquérito, desde que conjuntamente com provas produzidas "em contraditório judicial". De acordo, portanto, com a nova disposição legal, não se pode afirmar que todos os elementos produzidos no inquérito policial estejam descartados a priori, especialmente porque, na atualidade, o investigado não é mais visto como mero objeto de investigação, e sim como sujeito de direitos... Portanto, as provas produzidas durante o inquérito podem corroborar aquelas que foram produzidas em juízo, fortalecendo o panorama probatório e permitindo que se justifique a prolação de sentença condenatória. Desde que o magistrado não se apóie apenas em provas produzidas durante o inquérito, poderá valorá-las em conjunto com as provas produzidas em juízo, sempre

de maneira fundamentada”.

De outra parte, a defesa não trouxe aos autos elementos que evidenciassem interesse da vítima e das testemunhas em imputar falsamente ao acusado a prática de conduta definida como crime.

O crime se consumou, porque, mesmo com a restituição de parte dos objetos furtados, o furto atinge a consumação no momento em que o objeto material é retirado da esfera vigilância do sujeito passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor, ainda que a posse não seja tranquila e se dê por pouco tempo. No caso, a devolução dos celulares ocorreu em razão da ação dos policiais militares e da vítima, os quais conseguiram localizar e deter o acusado, depois da inversão da posse dos bens. Evidente, pois, a ocorrência do furto, em sua forma consumada. Como já dito, os bens foram encontrados na posse do acusado. A apreensão de bens furtados em poder do agente inverte o ônus da prova, de forma que deveria o acusado justificá-lo, de maneira inequívoca, mas assim não procedeu, pelo contrário, confessou a prática criminosa, o que transmuda em certeza qualquer dúvida acerca da autoria.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, restou caracterizada pela prova oral colhida durante a instrução (pelos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado). Essa qualificadora atinge todas as pessoas envolvidas na infração penal, ainda que não tenham praticado atos executórios e mesmo que uma só tenha estado no local do crime, porque a lei, ao utilizar a expressão concurso de duas ou mais pessoas, não faz qualquer distinção e abrange, por isso, tanto a coautoria quanto a participação.

Importante frisar que é pacífico que, para a configuração da causa de aumento relativo ao concurso de agentes, não há necessidade de identificação de todos os agentes, bastante a identificação de um deles e a comprovação de que o identificado estava na companhia de pelo menos mais um agente, requisito este cumprido, no caso dos autos.

Da mesma forma, restou comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, com fulcro nas declarações das vítimas e pelo laudo pericial de fls. 105/108.

De outra parte, restou comprovado que o furto foi cometido durante o repouso noturno da vítima, tratando-se de causa de aumento de pena, que será levada em conta na terceira fase da aplicação da pena.

Anoto que o entendimento deste Juízo é o de que é possível a cumulação entre os § 1º e 4º do artigo 155 do Código Penal, porque o primeiro se refere a uma causa de aumento de pena, aplicada na terceira fase de sua aplicação, ao passo que o § 4º é usado como qualificadora, elevando a um patamar maior a pena-base na primeira fase. Assim, além da robusta prova oral colhida na instrução, há também indício mais que suficiente para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Mesmo que assim não fosse, ressalto que o furto é delito, em regra, praticado na clandestinidade, por isso, a prova não é das contundentes, vistosas, bastando a apreciação adequada de elementos formadores da convicção e aptos a embasar um édito condenatório.

Diante desse quadro probatório, não há como se deixar de reconhecer que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, durante o repouso noturno, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em si 1 (um) celular da marca Samsung, modelo A31; 1 (um) celular da marca Samsung, modelo J7; 1 (um) televisor smart TV, marca Semp Toshiba, 43 polegadas; 1 (um) videogame Playstation

2, da marca Sony; 8 (oito) cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard; 1 (uma) mochila escolar de cor cinza; diversas joias e 1 (uma) aliança em ouro, pertencentes a Luciano da Silva Oliveira.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam sua culpabilidade ou extingam a punibilidade. Neste ponto, o fato de o acusado estar sob efeito de substância entorpecente, no momento dos fatos, não elide sua responsabilidade penal, pois estar sob efeito de droga (e também o fato de estar embriagado, de forma voluntária) voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do CP, e art. 45, caput, da Lei nº 11.343/06). A embriaguez que isenta de responsabilidade é a decorrente de caso fortuito ou força maior, isto é, provocada por causas alheias à vontade do agente, não a voluntária, a de quem bebeu ou se drogou porque quis, mesmo conhecendo os efeitos do álcool e da droga sobre o seu psíquico.

Ademais, a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental, além do que o réu se demonstrou lúcido em seu interrogatório.

Outrossim, embora o réu tenha dito em seu interrogatório que praticou o crime porque sua companheira e ele estavam passando por problemas financeiros, não há como reconhecer eventual estado de necessidade, já que não vislumbro a presença do perigo atual, como exigido pelo artigo 24, caput, do Código Penal, além do que poderia o réu ter realizado outras condutas lícitas que não a prática de furto. Entendimento contrário autorizaria que todas as pessoas que possuem dificuldades pudessem furtar bens de terceiro, o que é inadmissível.

Ademais, a jurisprudência é uníssona no sentido que a mera dificuldade financeira não autoriza o cometimento de crimes patrimoniais. Aliás, ainda que se admitisse a alegação trazida pelo réu, tal fato deveria ser demonstrado, mas não há nos autos qualquer nenhum indício sequer de que se encontrava nesta determinada circunstância.

Aliás, o réu não sequer arrolou como testemunha sua companheira, para que comprovasse sua condição de desempregado e dificuldade financeira, providência essa que seria de fácil consecução, caso fossem verdadeiras as narrativas apresentadas. Reconheço a ocorrência do delito e passo à aplicação da pena.

O acusado, conquanto primário e sem antecedentes, praticou furto duplamente qualificado (art. 155, § 4º, I e IV, CP). Nesse caso, uma qualificadora já serviu para qualificar o crime; a outra, portanto, é, neste momento, aplicada como circunstância judicial, já que o artigo 59 do Código Penal estabelece que, na fixação da pena-base, o juiz levará em conta as circunstâncias do crime, e todas as qualificadoras do § 4º referem-se aos meios de execução (circunstâncias) do delito.

Por conseguinte, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal não lhes são favoráveis, havendo motivos para a fixação da pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da menoridade penal relativa (menor de 21 anos na data dos fatos), e retorno a pena em seu patamar mínimo, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ainda nesta fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea, porque, embora tenha o réu confessado a prática do delito de furto qualificado em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo, durante o repouso noturno, alegou estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, procurando eximir-se de sua responsabilidade penal. Anoto que o entendimento deste Juízo é no sentido de que a confissão espontânea a que alude o artigo 65 do Código Penal, como circunstância determinante de alguma redução de pena, é aquela sem ressalvas, sem desculpas para o gesto criminoso, a qual não restou configurada no caso.

Ademais, ainda que se reconhecesse essa atenuante, ela não poderia ser aplicada, vez que a pena já se encontra em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, não existem causas de diminuição de pena a serem reconhecidas, no entanto, há uma causa de aumento, pois o crime se deu durante o repouso noturno,

conforme prova já acima analisada. Assim, elevo a pena em 1/3 (um terço), resultando em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda nesta fase, não é caso de aplicação do instituto do furto privilegiado, porque, apesar da primariedade do acusado, a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, conforme auto de avaliação de fl. 76. Não bastasse isso, trata-se de furto qualificado, razão pela qual o reconhecimento desse benefício, no caso, também seria insuficiente para a reprovação e prevenção da conduta praticada.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12, e o fato de o réu não ser reincidente ou possuidor de maus antecedentes, entendo que o regime de cumprimento do restante da pena corporal deverá ser aberto.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR BRUNO APARECIDO GOMES FERNANDES, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no seu valor mínimo unitário legal (art. 49 e parágrafos do CP), dando-o como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 08/03/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Embora o réu não seja reincidente, não possua maus antecedentes e a pena fixada não seja superior a quatro anos, entendo que, no caso, a substituição seria socialmente inadequada, já que o réu está respondendo processo por tráfico de drogas e furto, o que indica que a substituição do artigo 44 do Código Penal não é suficiente para a repressão e prevenção dos delitos. Afora isso, admitir uma pessoa usuária contumaz de droga prestar serviços em escolas e outras entidades públicas, colocaria em risco as pessoas que delas se utilizam, inclusive crianças inocentes, o que, de forma alguma, se pode admitir.

Diante da fixação do regime aberto para cumprimento do restante da pena, determino a imediata expedição de alvará de soltura clausulado em favor do acusado.

Importante e necessário esclarecer que, quanto à prisão cautelar do acusado, mantida até este momento, não houve qualquer ilegalidade, porque, até o final da instrução ocorrida em juízo, sob o crivo do contraditório, havia elementos para que a segregação cautelar fosse mantida, consoante fundamentação já exposta às fls. 43/47 e 127/128.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

P. R. I.

Birigui, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA